

1500749-15.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Ainda que o réu nessa data tenha alegado ter sido coagido a trabalhar no tráfico para pagar uma dívida de uso de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500749-15.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000579

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104099/2022 - 03º D.P.

DIADEMA, 2104099 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo Said da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

CARLOS EDUARDO SAID DA SILVA, qualificado às fls. 06/08, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 14 de abril de 2022, por volta das 19h00, na Rua Montevideu, altura do nº 100, Passagem Monte Alegre, e na Rua Canadá, nº 265, ambos nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 185 embalagens plásticas contendo 105g da droga cocaína, 385 embalagens plásticas contendo 76g da mesma droga, na forma de crack, e 594 embalagens plásticas contendo 960g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 17/18, laudos

de constatação provisória de fls. 20/22 e de exame químico-toxicológico de fls. 61/63, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.41/44), o réu foi notificado e citado (fls. 127/129), e apresentou defesa preliminar as fls.88/93, através do Advogado constituído. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 14/06/2022 (fls.111/112).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, sem a atenuante da confissão e sim a agravante da reincidência, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado além da perda do numerário apreendido.

Já o d. Advogado reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, e uso de tornozeleira, se o caso. É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.20/22 e 61/63), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls.03/05), realizava patrulhamento de força tática em operação "ABC Mais Seguro". Durante deslocamento pela Passagem Monte Alegre deparou com um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga a pé. Durante a fuga o indivíduo pulou um muro e ao cair, torceu o pé, sendo então detido. Em poder do suspeito foi encontrado um saco plástico contendo 10 porções de maconha, 08 porções de cocaína e 42 pedras de crack, além da importância de R\$ 70,00. Na busca pessoal realizada foi encontrada uma chave. Ao ser indagado, o suspeito declarou ser a chave de uma casa alugada para a guarda das drogas, pela qual disse pagar a importância de R\$ 450,00 por mês ao proprietário, porém não informou o nome dele. Em seguida o suspeito conduziu a equipe até a Rua Canadá, 265, e utilizaram as chaves que estava na posse do indiciado para abrir o portão e a porta da residência. Ao ingressarem na casa foi encontrado um saco plástico contendo 584 porções de maconha, 177 porções de cocaína e 343 pedras de crack, sendo o saco localizado no sofá que estava na cozinha. No local foi também encontrado um telefone celular e a carteira de identidade, identificando o indivíduo como sendo CARLOS EDUARDO SAID DA SILVA RG nº 39.929.485-5 SSP/SP. Esclareceu que aparentemente o indiciado não morava na residência, sendo o local utilizado somente para armazenamentos dos entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório o policial Matheus Campos alegou que passavam pela Passagem, ele viu a viatura, pulou o muro, caiu e se machucou. Com ele estava a sacola com as drogas. No bolso havia a chave de uma residência e ele disse que era

o local que alugava para guardar as drogas e fazer o abastecimento das drogas, há quinhentos metros do local apreenderam mais narcóticos, maconha, crack e cocaína, em bastante quantidade. Também apreenderam com o réu vinte reais proveniente da venda de drogas. Reconhece o réu e o local da prisão é um ponto de venda de drogas já conhecido. Só o réu correu e ele estava sozinho. Ele espontaneamente conduziu os policiais até a casa onde o restante das drogas estavam guardadas.

Igualmente o policial Marcelo Alves alegou que estavam em patrulhamento no local dos fatos, uma via de terra. Visualizaram um indivíduo que ao vê-los, correu. Foram atrás dele. Ele pulou uma mureta para dentro de uma viela, torceu o pé, e foi detido. Em posse dele tinha uma sacola plástica com sessenta porções de drogas e dinheiro. Com ele tinha uma chave que ele mesmo falou que armazenava as drogas para abastecer, repor. Ele mesmo os levou até o local, umas ruas para cima. Era um cômodo vazio e ali, numa sacola, haviam mais drogas. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu e o abordou. Ele confessou a venda das drogas e que o dinheiro apreendido era da venda das drogas. Tratava-se de cocaína, crack e maconha, mais de mil invólucros totais. O réu tentou fugir dos policiais, mas foi perseguido e detido ao se machucar e não conseguir andar mais. Com ele haviam sessenta porções dos dois tipos de drogas, e setenta reais em dinheiro junto.

O réu, em solo policial (fl.08) disse que irá se manifestar somente em Juízo. E desta feita o acusado confessou que estava traficando porque fez uma dívida, por ser usuário de crack e foi obrigado a trabalhar para o tráfico, ou lhe matariam e à sua família. Tentou fugir sim. Mas não alugou nenhuma casa, porque nem tinha condições de alugar nada. Os policiais lhe levaram para frente de uma casa e vieram com as drogas. Em seu poder tinha oito porções de cocaína, umas dez de maconha e dezesseis ou dezessete de crack e setenta reais das vendas dessas drogas. Nega que estivesse em poder de uma chave, porque em seu bolso só tinha uma pedra de crack e o dinheiro. É usuário de crack e tinha uma dívida de drogas a ser paga. Já teve passagem policial por assalto e estava cumprindo pena, e ainda faltava mais de um ano quando foi preso por esse tráfico.

Logo, a confissão (ainda que parcial) não é prova única e veio corroborada pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu optou pelo silêncio em solo policial, e os policiais trouxeram sempre a mesma versão, inclusive acerca das demais drogas localizadas num imóvel cuja chave estava com o acusado e que se ele não os tivesse conduzido até lá, não saberiam onde seria e não teriam apreendido o restante dos narcóticos. Além de ser pouco crível que as testemunhas falseiem a verdade quanto a esse segundo fato, que se verdadeiro não fosse, o normal e correto seria o réu já ter negado em solo policial a posse das drogas encontradas na casa, alegando que apenas as que estavam consigo lhe pertenceriam e que não estaria em poder de nenhuma chave, como fez apenas nessa audiência, depois que teve tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da Defesa.

Ressalto ainda o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Não bastasse isso, os policiais sempre afirmara que o réu, por eles reconhecido, foi o indivíduo que correu assim que percebeu suas presenças, e que era ele quem portava parte das drogas e uma chave de uma casa onde encontraram mais narcóticos, das mesmas naturezas, embalados individualmente. E ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta

prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar, ter em depósito e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Ainda que o réu nessa data tenha alegado ter sido coagido a trabalhar no tráfico para pagar uma dívida de uso de drogas, por ser viciado em crack, não fez prova de nada disso como lhe competia o ônus dessa prova. Inclusive, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (779 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de numerário proveniente das vendas de drogas (R\$70,00) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como excessiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (779 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, valendo-me ainda do princípio da proporcionalidade, ou seja, quanto mais drogas maior a pena, fixo-a, em primeira fase, acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fl. 33/34 - condenação por roubo pela 3ª Vara Criminal de Diadema) a qual compenso com a atenuante da confissão judicial espontânea, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012), ainda que o acusado só tenha confessado parcialmente os fatos nessa audiência, mas foi por sua confissão informal e sua conduta de conduzir os policiais até o local do armazenamento que a maior parte dos narcóticos foi apreendido, de modo que ele colaborou com a busca da verdade real e ora lhe beneficia tal conduta, de modo que a pena resta inalterada nesta etapa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, ainda que não específico, o que a lei não exige, e a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que

um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso. Assim, a pena final é de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional fechado, considerando a quantidade da pena, a reincidência do réu, quem estando em cumprimento de pena, tornou a delinquir, e também pela preponderância da natureza e da qualidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no RESp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário), não sendo nem socialmente recomendável. Ademais: Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime. (TJAP) RT 772/617.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido

contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra CARLOS EDUARDO SAID DA SILVA, qualificado às fls. 06/08 como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 Ufesp's, nos termos da lei nº 11.608/03, ante a constituição de Advogado.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Decreto a perda de numerário apreendido (fl.11), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA